

Photo : XR/Rue89 Bordeaux

DROIT DU TRAVAIL

L3 AES

Cours de Matthieu Vicente

Séance 3

Chapitre 2 : Le recrutement du salarié

§1 : La procédure du recrutement

§2 : L'issue du recrutement : la formation du contrat de travail

§1. La procédure de recrutement

Principe : la liberté d'embauchage

Cons. const., Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988

En pratique cependant : de nombreuses limites posées par la loi

A. Les modalités de recrutement

- Recrutement direct
  - *Interne (promotion)*
  - *Externe (par contact privé ou publiquement)*

  Article L5331-3

- Recrutement par le biais d'un intermédiaire
  - *Intermédiaire public France Travail*

  Article L5412-1

  Article L5411-6-1

- Intermédiaire privé :

  → Opérateurs privés de placement

  Article L5321-1

  → Les agences de recrutement

  = des représentants de l'employeur, sélectionnent en son nom les candidats à un emploi déterminé.

  Obligation de moyen et non de résultat.

B. Les opérations de recrutement

- **Limitation des informations demandées au candidat**

L1221-6 :

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.

L1221-8 :

Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

Double règle de :

- Finalité
- Pertinence

B. Les opérations de recrutement

- **Information du candidat**

L1221-8

Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. (...).

L1221-9

Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

L2312-38

Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.

B. Les opérations de recrutement

- **Confidentialité**

L. 1222-3

Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Respect du RGPD :

- *Consentement du salarié*
- *Droit d'accès, de modification et de suppression*
- *Droit à l'oubli*
- *Alerte en cas de fuite de données*

C. Les limites à la liberté d'embauchage

- **Interdictions d'emploi en raison de la situation personnelle du travailleur**
  - *Interdictions liées à l'âge : L. 4153-1*

  Sauf exceptions
  - *Étrangers en situation irrégulière : L. 8251-1*
  - *Respect de la durée maximale du travail journalière ou hebdomadaire*
  - *Débauchage illicite : L. 1237-3*

  - *Clauses spécifiques (clause d'exclusivité, clause de non concurrence)*
  - *Interdictions de cumul spécifiques*

C. Les limites à la liberté d’embauchage

- **Priorités d’embauche**

  - Travailleurs handicapés (OETH) , L. 5212-2

  Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

  - Priorités de réembauche :
    - Travailleurs licenciés pour motif économique, L. 1233-45
    - Salariés à temps partiel

C. Les limites à la liberté d'embauchage

- **L'interdiction des discriminations**
  - ***Principe général***

L. 1132-1

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…), notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

C. Les limites à la liberté d'embauchage

- L'interdiction des discriminations
  - *Précisions jurisprudentielles*

Cass. soc. 18 janvier 2012, n° 10-16.926 : le simple fait d'avoir retardé un recrutement pour un motif discriminatoire est suffisant à caractériser la discrimination.

CJUE 10 juillet 2008, C-54/07, *Feryn* : les déclarations publiques par lesquelles un employeur annonce qu'il ne recrutera pas de candidats d'une certaine origine ethnique ou raciale sont en elles-mêmes discriminatoires, sans qu'il soit nécessaire d'identifier une victime

C. Les limites à la liberté d'embauchage

- L'interdiction des discriminations
  - *Régime probatoire*

L. 1134-1 et L. 1144-1 :

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, (…).

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Sanctions :

- Nullité, L. 1132-4
- Poursuites pénales, 225-2 C. pén. : 3 ans empr. 45 000€ d'amende

C. Les limites à la liberté d'embauchage

- L'interdiction des discriminations
  - *Précisions sur les discriminations sexistes*

Article L1142-1

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

Sanction : 1 an empr. 3 750€ d'amende

C. Les limites à la liberté d'embauchage

- L'interdiction des discriminations
  - *Précisions sur les discriminations sexistes*

Selon vous, parmi les emplois suivants, lesquels autorisent la mention du sexe lors du recrutement ?

1_ membre de l'équipage d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin

2_ maçon

3_ vendeuse dans un magasin de sous-vêtements féminin

4_ artiste, interprète et modèle

5_ nourrice

6_ sage-femme

C. Les limites à la liberté d’embauchage

- L’interdiction des discriminations
  - *Discriminations autorisées*

R. 1142-1

Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :

1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;

2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;

3° Modèles masculins et féminins.

C. Les limites à la liberté d'embauchage

- L'interdiction des discriminations
  - *Précisions sur les discriminations sexistes*

Sur l'état de grossesse :

L. 1225-1

L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.

Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

D. Les formalités du recrutement

- La déclaration préalable à l'embauche (DPAE)
- Information du salarié sur les éléments essentiels de son contrat
- Information sur la convention collective
- Inscription sur le registre unique du personnel
- Visite d'information et de prévention (dans les 3 mois)

Article L4624-1

Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.

Chapitre 2 : Le recrutement du salarié

§1 : La procédure du recrutement

§2 : L'issue du recrutement : la formation du contrat de travail

§2. L’issue du recrutement et la formation du contrat de travail

Article 1128 du Code civil

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

A. Les conditions de formation du contrat

- **Un consentement libre**

1130 C. civil

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

1137 C. civil

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L1221-6 C. trav. :

(...) Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.

A. Les conditions de formation du contrat

- **Un consentement libre**

Le mensonge du salarié lors de l'embauche peut vicier la formation du contrat

Ex. : CA Lyon 25-6-2010 n° 09-6376, B. c/ SA Lyonnaise de banque

Cependant :

- Les omissions et inexactitudes du salarié lors de son embauche ne sont constitutives d'un dol que si elles portent sur un élément déterminant pour la conclusion du contrat de travail. Exemple, CA Paris 8 mars 2000, n°98-3458, SARL Repères c/ SARL LOM Consultants
- L'employeur a l'obligation de vérifier certaines informations ; ex. : Cass. soc. 30 avril 1991, n°88-42.029 D ; Cass. soc. 16 févr. 1999, n°96-45.565

A. Les conditions de formation du contrat

- **Problématique de la promesse d'embauche**

Cass. soc. 21 sept. 2017, n°16-20.103

➢ **L'offre de contrat de travail**

Il s'agit de l'offre, faite par l'employeur à une personne déterminée ou indéterminée, qui comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Elle n'implique pas la formation d'un contrat. L'employeur peut se rétracter tant que le travailleur n'a pas reçu l'offre, car le contrat n'est pas formé.

Illustration : la lettre rédigée de la manière suivante : « Suite à notre entretien, nous vous confirmons votre embauche en contrat à durée indéterminée, au plus tard le X aux conditions suivantes… », mais subordonnant la conclusion du contrat à l'acceptation du candidat (CA Poitiers 2-5-2018 n° 16/03766).

➢ **La promesse de contrat de travail**

Dans ce cas de figure, le contrat est formé, mais le salarié dispose d'une option temporaire. L'employeur ne peut pas se rétracter, car le contrat est déjà formé.

Illustration : employeur ayant adressé à un candidat un exemplaire du contrat de travail et des simulations de salaire, l'intéressé n'ayant pas retourné ce document contractuel signé mais ayant accepté l'offre par courriel sans équivoque (CA Colmar 11-12-2018 n° 17/04877)

A. Les conditions de formation du contrat

- Capacité de contracter
- Objet licite et certain

B. Sanction des conditions de fond

- **Nullité :**
  - *Absolue ou relative*
  - *Non-rétroactive*